

<제08장 청구의 병합과 소의 변경.제02절 소의 변경>

[예상][8.02-1]취소소송에서 부작위위법확인소송으로의 소의 종류의 변경의 요건 및 허용 범위

《【문제8.2】

<사례>

행정청 A는 甲에게 `개발행위허가 거부처분`을 내렸다. 甲은 해당 거부처분이 위법하다고 판단하여 처분의 취소를 구하는 `취소소송`을 법원에 제기하여 현재 제1심 소송이 계속 중이다. 소송이 진행되던 중 甲은 법률 전문가의 조언을 듣고 취소소송보다는 `부작위위법확인소송`으로 소송의 종류를 바꾸는 것이 유리하겠다고 판단하여 소를 변경하고자 한다. 한편, 乙은 행정청 B로부터 `영업정지 6개월 처분`을 받고 취소소송을 제기하여 심리 중인데, 행정청 B가 소송 중에 乙의 정상을 참작하여 해당 처분을 `영업정지 2개월`로 감경하는 처분을 별도로 내렸다.

(물음1) 甲이 현재 진행 중인 `취소소송`을 `부작위위법확인소송`으로 변경하고자 할 때, 행정소송법 제21조에 따른 `소의 종류의 변경`의 요건과 허용 범위에 대하여 설명하라.》

<문제8.2의 물음1> 취소소송에서 부작위위법확인소송으로의 소의 종류의 변경의 요건 및 허용 범위

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 개발행위허가 거부처분 취소소송이 계속 중인 상태에서 부작위위법확인소송으로 소송의 종류를 변경하려는 상황이다. 쟁점으로 <행정소송법 제21조에 따른 소의 종류 변경이 인정되기 위한 요건과 취소소송에서 부작위위법확인소송으로의 변경이 허용되는 범위>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 소의 종류 변경 제도의 의의와 요건 및 그 허용 범위에 대해 설명한다.

II. 소의 종류의 변경의 의의 및 성질

1. 의의

- 소의 종류의 변경이란 원고가 제기한 소송을 다른 종류의 항고소송이나 당사자소송으로 변경하는 것을 말한다. 이는 소의 제기 후에 발생한 사정변경에 대응하거나, 당초 소 제기가 잘못된 경우 원고의 권리구제를 도모하고 소송경제를 실현하기 위한 제도이다.

2. 법적 성질

- "행정소송법 제21조"에 의한 소의 변경은 구소(취소소송)를 취하하고 신소(부작위위법확인소송)를 제기하는 성격을 동시에 가진다. 이때 신소는 구소가 제기된 때에 제기된 것으로 보아 제소기간 준수 여부를 판단하게 되는 소급효의 특징이 있다.

III. 소의 종류의 변경의 요건

1. 소의 계속과 사실심 변론종결 전

- 변경하고자 하는 구소가 법원에 적법하게 계속되어 있어야 하며, 소의 변경 신청은 사실심(제1심 또는 제2심)의 변론종결 전까지 이루어져야 한다. 사안의 甲은 제1심 소송이 계속 중이므로 이 요건을 충족한다.

2. 청구의 기초의 동일성

- 소의 변경은 청구의 기초에 변경이 없는 범위 내에서 허용된다. 이는 구소와 신소가 동일한 행정작용이나 사실관계에 근거하고 있어 소송자료를 공통적으로 활용할 수 있는 경우를 의미한다. 甲의 경우 개발행위허가 신청에 대한 행정청의 반응(거부 또는 부작위)을 다투는 것이므로 청구의 기초가 동일하다고 볼 수 있다.

3. 신소의 적법성

- 변경되는 신소인 부작위위법확인소송은 그 자체로 소송요건을 갖추고 있어야 한다. 다만 제소기간의 경우 "행정소송법 제21조 제4항" 및 "제14조 제4항"에 따라 구소가 제기된 때에 제기된 것으로 간주되므로 구소의 제소기간 내 제기 여부가 중요하다.

4. 법원의 재량과 피고의 의견 청구

- 법원은 소의 변경이 상당하다고 인정할 때 결정으로써 허가한다. 이때 법원은 피고의 의견을 들어야 한다. 피고가 소 변경에 반대하더라도 청구의 기초가 동일하고 변경의 필요성이 인정된다면 법원은 이를 허가할 수 있다.

IV. 소의 종류의 변경의 허용 범위와 사안의 특수성

1. 변경의 방향

- "행정소송법 제21조"는 항고소송 상호 간(취소소송 ↔ 무효확인소송 ↔ 부작위위법확인소송)의 변경뿐만 아니라 항고소송과 당사자소송 간의 변경도 허용한다.

2. 거부처분 취소소송과 부작위위법확인소송의 관계

(1) 처분의 존재 여부

- 사안에서 행정청 A는 이미 거부처분을 내린 상태이다. 부작위위법확인소송은 행정청이 신청에 대하여 상당한 기간 내에 일정한 처분을 하여야 할 법률상 의무가 있음에도 불구하고 이를 하지 아니하는 경우에 제기하는 소송이다.

(2) 소 변경의 허용 범위에 관한 고찰

- 거부처분이 엄연히 존재하는 상황에서 이를 부작위로 보아 부작위위법확인소송으로 변경하는 것은 원칙적으로 대상적격의 흠결 문제를 발생시킬 수 있다. "판례"에 따르면 거부처분이 있는 경우에는 부작위위법확인소송을 제기할 수 없다. 따라서 甲이 소를 변경하려 할 때, 법원은 단순히 소 변경의 절차적 요건뿐만 아니라 변경된 신소가 부작위라는 요건을 실질적으로 충족하는지를 심사하게 된다. 만약 거부처분의 통지가 도달하지 않았거나 행정청의 반응이 부작위로 해석될 여지가 있다면 소 변경이 유효할 것이나, 명확한 거부처분이 있는 상황에서의 변경은 부적법한 신소로 귀결될 위험이 있다.

V. 결론

- 甲이 제기한 취소소송을 부작위위법확인소송으로 변경하는 것은 "행정소송법 제21조"에 따라 사실심 변론종결 전까지 청구의 기초가 동일하다면 신청할 수 있다. 소 변경이 허가되면 신소는 구소 제기 시에 제기된 것으로 간주되는 유리함이 있다. 다만, 사안에서 행정청 A의 명시적인 거부처분이 존재하는 상황이라면 변경된 부작위위법확인소송은 대상적격 흠결로 각하될 가능성이 높으므로, 甲은 법률 전문가의 조언에도 불구하고 실질적인 소송의 실익을 신중히 검토해야 한다. 이러한 법리는 원고의 주관적 권리구제를 넓게 보장하면서도, 소송 대상의 성질에 따른 소송 종류의 적정성을 유지하려는 행정소송법의 태도를 반영한다.